[法学]

农地开发许可权市场化改革的法理逻辑

——兼论私法的方式如何实现土地管理的目标

张先贵

[摘　要] 农地开发许可权乃是我国《土地管理法》确定的农用地转用审批程序的法权表达。农用地转用审批程序的核心在于是否持有农用地转用指标。理论上，“自上而下、统一分配、层层分解、指令性配额”的农用地指标管理运作模式，其本质上乃是我国土地管理践行“命令—服从”之单一公法方式的体现。实践中，规避农用地转用审批程序、违法实施农用地转用的现象较为普遍，这折射出农地开发许可权的运行陷入失灵的困境。从“两分两换”、城乡建设用地“增减挂钩”到“地票”交易的政策演进脉络，虽形式上突围了现行农用地转用审批制度下指标计划外取得的困境，具有化堵为疏的制度功能和价值，但其背后的逻辑乃是对农地开发许可权进行市场化改革的本质宣示，是农地开发许可权在国家治理现代化背景下的重大制度创新。在法理逻辑层面，对农地开发许可权进行市场化改革，体现了在一定条件下可借助私法的方式完成土地管理任务，实现土地管理目标的“行政私法”原理。当然，这亦是“行政私法”原理在我国土地管理领域的深化发展、机制创新和实践体现。我国现行的土地管理法律制度亦应该以此为契机和切入点来展开实质性的改革。

[关键词] 农用地转用审批；农地开发许可权；公法；私法

[中图分类号] D912.3　[文献标识码] A　[文章编号] 1000－5072(2018)04－0099－12

一、问题之提出

1986年我国制定了《土地管理法》，标志着我国对土地资源的管理步入了法制化的轨道。为适应土地管理实践不断发展的需要，我国于1988年、1998年和2004年分别对《土地管理法》进行了不同程度的修改。其中修改幅度最大的当属1998年的《土地管理法》之修订，即首次确立了“土地用途管制法律

作者简介：张先贵，上海海事大学法学院副教授，法学博士，华东政法大学法学博士后。

基金项目：国家社会科学基金青年项目“‘准征收’与行政补偿法律制度研究”(批准号：17CFX012)；教育部哲学社会科学重大攻关项目“农村土地股份制改革的理论探索与制度设计”(批准号：13JZD007)；中国博士后科学基金第61批面上资助项目(批准号：2017M611508)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

制度”,[①] 打破了原先根据所有权制度确定的“城乡二元管理体制”。[②] 根据我国现行《土地管理法》第四条所确定的土地用途管制的法律制度规定,农地权利人是不能随意变更农用地用途管制从事农地非农化开发建设,而地方政府在执行土地用途管制,禁止农地权利人擅自变更农用地用途管制的同时,自己亦必须严格遵守这一制度的规定,不得随意将农用地转为非农用地从事农地非农化开发建设。[③] 但由于地方政府兼有“管理者”和“经营者”的双重角色,其不仅需要管理好本地区的土地资源的开发和利用,[④] 而且亦担负着发展地方经济的重任。尤其是在当前工业化、城镇化迅速发展以及地方政府官员晋升与土地财政相关联的背景下,[⑤] 为“满足以消耗土地为主要特征的发展模式”[⑥]的需要,通过征收的方式,将城市周边农村集体土地转为国有土地,来解决城市建设发展过程中对土地的需求,已成为当下地方政府发展经济的重要模式。[⑦] 是故,在这一背景下,将农地转为非农用地从事农地非农化开发建设已成不可避免的客观趋势。[⑧]

根据我国《土地管理法》第四十四条的规定,地方政府(主要是县、市政府)有权将农用地转为非农用地从事农地非农化开发建设,但需要办理农用地转用审批程序。法理上,农用地转用审批程序的设置,是对农用地用途变更进行程序上严格控制的表现,“其目的是为了防止地方政府随意变更农用地用途管制,造成国家耕地资源的减少,影响国家粮食安全目标的实现”。[⑨] 实践中,国务院或者省级人民政府对县、市级人民政府申请办理农用地转用进行审批时,主要是看其是否持有农用地转用指标。[⑩] 换言之,数量化的农用地转用指标成为农用地转用审批程序的核心内容。[⑪] 唯有持有农用地转用指标,方可获得审批,进而有权将农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设。因此,在本质上,农用地转用审批程序乃农地开发许可权的本质体现。回置到法权语境中,农地开发许可权乃农用地转用审批程序的法权表达。[⑫] 由于我国相关的法律、政策和实践对农用地转用指标采用“自上而下、统一分配、层层分解、指令性配额”的运作管理模式。实践中,各县、市人民政府基于经济发展的不平衡、可复垦的后备土地资源不等以及信息不对称等客观因素的存在,在获得上级政府所分配的年度农用地转用指标

① 《土地管理法》第四条规定 “国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。前款所称农用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等;建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等;未利用地是指农用地和建设用地以外的土地。使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。”

② 董礼洁 《地方政府土地管理权》,北京:法律出版社 2009 年版,第 14 页。

③ 参见孙建伟 《论宅基地“长期使用”权》,《暨南学报》(哲学社会科学版) 2016 年第 3 期;郭洁 《土地用途管制模式的立法转变》,《法学研究》2013 年第 2 期。

④ 《土地管理法》第一条规定 “为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定本法。”

⑤ 刘佳、吴建南、马亮 《地方政府官员晋升与土地财政——基于中国地市级面板数据的实证分析》,《公共管理学报》2012 年第 2 期。

⑥ 谭明智 《严控与激励并存:土地增减挂钩的政策脉络及地方实施》,《中国社会科学》2014 年第 7 期。

⑦ 邹薇、刘红艺 《土地财政“饮鸩止渴”了吗——基于中国地级市的时空动态空间面板分析》,《经济学家》2015 年第 9 期。

⑧ 尽管当下我国某些地区已经严格控制农地非农化开发建设,严格控制新增建设用地的增加,并在规划层面实行了减量规划,但就全国来看,在新型城镇化背景下,变更农用地用途管制从事农地非农化开发建设的现象,仍然是目前的主要趋势。与之相适应的是,在土地规划上仍然践行的是增量规划,参见刘红梅等 《经济发达地区建设用地减量化研究——基于“经济新常态下土地利用方式转变与建设用地减量化研讨会”的思考》,《中国土地科学》2015 年第 12 期;陈宏胜、王兴平、国子健 《规划的流变——对增量规划、存量规划、减量规划的思考》,《现代城市研究》2015 年第 9 期。

⑨ 邹爱华 《完善土地征收审批制度的基本思路与具体对策》,《国家行政学院学报》2011 年第 2 期。

⑩ 张至波 《相乡级土地规划如何分配指标》,《中国土地》2006 年第 9 期。

⑪ 童江欣、陈向春 《农用地转用审批对耕地保护的缺陷分析》,《国土资源》2006 年第 4 期。

⑫ 这一定性可避免农用地转用审批这一事实行为游离于法律思维之外,而处于文本上的灰色地带。具体论证详见张先贵 《农用地变更许可的法权表达》,《重庆社会科学》2016 年第 4 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

数量方面往往存在较大的差异。[①] 尤其是在经济发达地区，当通过行政分配方式所获得的农用地转用指标无法满足经济发展的需要时，实施各种规避农地开发许可权的违法行为，擅自将农用地转为建设用地从事农地非农化开发建设的违法现象时常发生。[②] 因而，从某种意义上讲，这宣示了当下农地开发许可权的行使已步入了失灵的困境。[③] 为破解这一难题，在地方的土地管理改革实践中，从早期的“两分两换”[④]模式、到城乡建设用地“增减挂钩试点政策”[⑤]模式，再发展到后来的“地票”[⑥]交易模式，都是在不断地试图借助市场方式来解决农用地转用指标行政供给不足这一难题，从而突围现行农地开发许可权运行失灵的困境。相比较而言，目前，以成渝两地为代表的“地票”交易模式是市场化水平程度较高的，亦是较为成熟的模式，[⑦] 并已在许多地区得到推广应用。[⑧]

由此不难看出，尽管我国现行实证法上围绕农地开发许可权践行的是以“命令—服从”为单一公法方式的制度设计，但当下围绕农地开发许可权市场化的诸多政策试点方案，却在一定程度上宣示改革这一制度的必要性和急迫性。这由此而带来的问题是：为何要对现行法上的农地开发许可权进行市场化改革？或者说改革的正当性诉求何在？如何从法理层面来审视我国当下围绕农地开发许可权市场化改革这一实证模式？另外，现有的改革试点经验对深化我国现行土地管理制度改革有何启示意义？有鉴于此，下文拟围绕我国农地开发许可权市场化改革这一主题展开深入探讨，以期为我国现行农地开发许可权法律制度的未来改革提供正确的理论指导。

二、何以生成：农地开发许可权市场化改革正当性诉求

从理论层面求解我国现行农地开发许可权市场化改革的正当性诉求，不仅为我国现行《土地管理法》中农用地转用审批法律制度的修改提供法理支撑，而且亦有助于进一步推动我国农地开发许可权市场化改革实践的顺利开展。在笔者看来，当下对农地开发许可权进行市场化改革的真正动因在于，在市场经济迅速发展的当下，传统以“命令—服从”为单一公法方式的农地开发许可权的行使模式已逐渐步入了制度运行失灵的困境，为回应多元化市场主体的利益诉求，亟须按照市场取向来进行改革。关涉我国农地开发许可权市场化改革正当性诉求的具体理据如下：

其一，对我国农地开发许可权进行市场化改革，是破解当下我国农用地违法转用这一难题的现实需要。就我国现行土地资源配置实践而言，“作为土地资源基本配置主体的政府，主要是通过规划、计划的管控作用来配置土地资源”。[⑨] 这在现行立法关涉农地开发许可权的指标运行管理模式中体现得尤为明显。前文已述，实践中，地方政府是否持有新增建设用地指标直接决定了能否将农用地转为建设

① 参见曾光建、陶军德、关国锋、刘杰 《新一轮土地利用总体规划中建设用地指标分解研究——以伊春市为例》，《资源与产业》2010 年第 4 期；雾豪、李江风、张徽 《不完全信息动态博弈模型在建设用地指标分配中的运用——以广西桂林市资源县为例》，《国土资源科技管理》2010 年第 1 期。

② 参见刘法威 《经济增长与违法用地的关系分析》，《资源科学》2010 年第 8 期；朱红梅、刘庆、谭洁 《论县域违法用地治理与耕地保护》，《湖南农业大学学报》(社会科学版) 2007 年第 2 期；陶友金，张全景 《我国违法用地行为的空间与时序特征分析》，《资源与人居环境》2013 年第 7 期。

③ 郭洁 《土地用途管制模式的立法转变》，《法学研究》2013 年第 2 期。

④ 孙建伟 《城乡建设用地置换中的“自愿”原则及其悖论》，《苏州大学学报》(哲学社会科学版) 2013 年第 6 期；刘锦城 《“两分两换”背景下的失地农民就业权研究——以浙江嘉兴为例》，《当代法学》2012 年第 2 期。

⑤ 邹清平 《“十三五”时期城镇化发展用地政策分析——关于增减挂钩政策的探讨》，《中国土地》2016 年第 1 期。

⑥ 张先贵 《地票交易之地役权属性的理性检视》，《社会科学研究》2016 年第 1 期。

⑦ 冯应斌、杨庆媛、慕卫东、刘燕 《地票交易制度创新成效及其推广复制建议》，《经济体制改革》2016 年第 6 期。

⑧ 朱凤凯、张凤荣、李乐 《农地非农化视角下地票交易供给侧的激励机制及空间效应研究》，《中国土地科学》2016 年第 10 期。

⑨ 郑振源 《建立开放、竞争、城乡统一而有序的土地市场》，《中国土地科学》2012 年第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用地从事农地非农化开发建设,[①] 并且持有新增建设用地指标的数量亦直接决定了农用地转用的规模。[②] 而对于新增建设用地指标的获取和配置,我国现行立法主要采取的做法是,由国家通过事先规划的方式来确定总量指标,[③] 然后通过自上而下的方式"统一分配、层层分解、指令性配额管理"的模式来运作,这在我国《土地管理法》第十八条中得到充分的体现,即"下级土地利用总体规划应当依据上一级土地利用总体规划编制。地方各级人民政府编制的土地利用总体规划中的建设用地总量不得超过上一级土地利用总体规划确定的控制指标,耕地保有量不得低于上一级土地利用总体规划确定的控制指标。"

一般而言,国务院编制土地利用总体规划中确定 10 ~ 15 年的新增建设用地总量指标,[④] 国土资源部编制土地利用年度计划确定每年的新增建设用地指标总量。[⑤] 然后在此基础上,再通过自上而下的方式"统一分配、层层分解",一直下达乡镇。下级地方政府取得新增建设用地指标后,意味着有权变更农用地用途管制,从事农地非农化开发建设。但鉴于指标是通过行政权力分配取得的,因此,下级行政机关要服从上级行政机关对指标的行政管理要求。由此可见,对新增建设用地指标实行的指令性配额管理模式,与计划经济背景下对土地资源的计划配置方式并无本质性的区别,或者说,是计划经济背景下土地资源行政配置的实质体现。因而,在法理上讲,这一做法体现了现行农地开发许可权践行的是"命令—服从"的单一公法方式。

客观而言,在这一模式(即指标的"总量控制、统一分配、层层分解、指令性配额管理")中,国家对新增建设用地实行中长期和年度指标总量控制,具有其相应合理性:一方面,土地不仅是一项财产,亦是一项资源,作为承载社会公共利益的土地资源,其配置离不开国家的行政干预。[⑥] 国家通过对新增建设用地实行指标总量控制,实际上乃是中央政府借助数字化的指标对地方土地资源开发建设进行宏观调控的体现,[⑦] 这对优化城乡建设用地资源的空间配置,合理利用、开发土地资源,保护有限的 18 亿亩耕地红线,实现国家粮食安全的目标具有十分重要的意义;另一方面,在"法律数字化现象"[⑧]的今天,通过对城市新增建设用地实行指标总量控制,实施偏紧的新增建设用地指标供给方案,不仅有助于优化城市存量建设用地的结构,改变目前城市建设用地低效、粗放利用的弊病,[⑨] 而且可在一定程度上有助于遏制城市经济快速发展而带来的经济泡沫现象。这对实现社会经济的可持续健康发展具有非常重要的意义。[⑩]

---

① 参见刘澄宇、龙开胜 《集体建设用地指标交易创新:特征、问题与对策——基于渝川苏浙等地典型实践》,《农村经济》2016 年第 3 期。

② 参见陈书荣、陈宇 《土地审批制度的供给侧改革:征批分离》,《中国土地》2016 年第 2 期。

③ 参见《土地管理法》第十七条规定 "各级人民政府应当依据国民经济和社会发展规划、国土整治和资源环境保护的要求、土地供给能力以及各项建设对土地的需求,组织编制土地利用总体规划。"

④ 参见《土地管理法实施条例》第九条规定 "土地利用总体规划的规划期限一般为 15 年。"

⑤ 参见《土地管理法》第二十四条规定 "各级人民政府应当加强土地利用计划管理,实行建设用地总量控制。土地利用年度计划,根据国民经济和社会发展计划、国家产业政策、土地利用总体规划以及建设用地和土地利用的实际状况编制。土地利用年度计划的编制审批程序与土地利用总体规划的编制审批程序相同,一经审批下达,必须严格执行。"《土地管理法实施条例》第十三条规定 "各级人民政府应当加强土地利用年度计划管理,实行建设用地总量控制。土地利用年度计划一经批准下达,必须严格执行。土地利用年度计划应当包括下列内容:(一)农用地转用计划指标;(二)耕地保有量计划指标;(三)土地开发整理计划指标。"

⑥ 参见郑振源 《建立适应土地资源市场配置的国家宏观调控体系》,《中国土地科学》2012 年第 3 期。

⑦ 参见王兴、杜新波、杨景胜 《土地宏观调控的机制框架与对策研究》,《资源与产业》2011 年第 2 期;丰雷 《土地宏观调控的政策体系设计——基于中国实践的分析》,《经济问题探索》2010 年第 9 期。

⑧ 曲笑飞 《法律数字化现象研究》,《法律科学》2013 年第 1 期。

⑨ 陈阳 《论我国土地督察制度良善化进路》,《东方法学》2017 年第 2 期;姜仁荣 《城市土地二次开发问题研究》,《中国土地》2012 年第 11 期。

⑩ 这在我国经济结构亟须实施供给侧结构改革的当下,体现得尤为明显。实施偏紧的新增建设用地指标供应政策,加大对存量建设用地的整理,改变目前建设用地供应结构的粗放状态,严格控制非农建设用地的供应,是我国目前土地管理领域制度改革的重要法制课题,参见孙祥智 《农业供给侧结构性改革的基本内涵与政策建议》,《改革》2016 年第 2 期;丁任重 《关于供给侧结构性改革的政治经济学分析》,《经济学家》2016 年第 3 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

但须指出的是，对新增建设用地实行指标总量控制，虽然有助于国家在宏观上把握经济的整体发展态势，有助于社会经济的稳健、有序发展，但指标的行政分配乃是国家对未来各地、各行业、各地区经济发展在建设用地需求层面的预测。显然，由于人类理性的有限性，在确定未来用地规划指标时，很难与实际用地需求相吻合，很难形成需求与供给上的对称性。① 另外，在“不确定性贯穿于土地利用规划管理过程始终”②的背景下，单纯的指令性计划经济管理方式显然难以应对瞬息万变的现实需要。因此，规划或计划与实践之间出现错位或者脱节的现象亦就在所难免。

另外，在对新增建设用地指标总量确定后，对于指标的分配则通过自上而下的“层层分解、统一分配”的模式来满足各级政府的用地需求。这一模式亦存在诸多弊端：一方面各地经济发展水平不同，对新增建设用地指标的需求不同，借助行政权确定各地的指标并进行分配难以满足当地经济发展对用地指标的真实需求。实践中，常出现这样的现象，经济发展较快的地区对用地指标的需求往往相对比较旺盛，但上级政府分配的指标则明显不足。而经济发展较慢的地区，上级政府分配的指标反而明显过剩。③ 在这一背景下，尤其是行政分配的指标难以满足地方政府的需求时，往往会出现两种局面：一是计划束缚实践，遵守用地指标的行政指令性配额管理模式，不再变更农用地用途管制从事农地非农化开发建设；二是在发展经济带来的各种利益的诱惑下，违反用地指标行政指令性配额管理模式，违法变更农用地用途管制，从事农地非农化开发建设。对于第二种情形，最为典型的违法现象是“以租代征”。④ 所谓“以租代征”，即地方政府(主要是县、市政府)为了将农用地转为建设用地，从事农地非农化开发建设，绕开国家的农用地转用审批、土地征收审批等程序规定，直接与农村集体经济组织之间达成租赁农用地协议，并将租赁的农用地转租给相关的用地单位或者个人从事农地非农化开发建设。从我国的土地管理实践来看，“以租代征”这种隐形土地违法行为较为常见;⑤ 另一方面，由于用地指标对地方经济发展的重要作用，各级地方政府往往不择手段地讨好上级政府以获得更多的计划外用地指标。而用地指标的这种行政权分配方式又为上述“权力寻租”违法现象的发生提供了制度上的土壤。在这一背景下，“管制被俘获”的违法现象时常发生在指标分配的运行实践中，亦就不足为奇了。⑥

由此可见，现行农地开发许可权法律制度所暴露出来的内在系统性缺陷，已难以适应当下社会经济迅速发展的需要，难以回应多元化市场主体的利益诉求。因而，实践中制度运行步入失灵的困境实属意料之中，难以避免。由此而带来的问题是，针对地方政府违反农用地用途管制，从事农地非农化开发建设的违法行为，究竟是秉持传统的进一步严格土地管理的执法机制，还是着眼于问题的本质和根源，对现行的农地开发许可权法律制度进行实质性改革，以此来突围制度运行失灵的困境?在笔者看来，长期以来，针对我国土地管理领域出现的诸多违法现象，“加强”、“进一步加强”、“严格”或者“进一步严格”执行土地管理的决定，几乎成为我们处理违法用地问题的惯用思路

① 吴次芳、邵霞珍 《土地利用规划的非理性、不确定性和弹性理论研究》，《浙江大学学报》(人文社会科学版) 2005 年第 4 期。

② 王卉、王群 《土地利用规划管理中的不确定因素及其影响分析》，《广东土地科学》2011 年第 6 期；张先贵 《容积率指标交易的法律性质及规制》，《法商研究》2016 年第 1 期。

③ 参见花盛 《土地规划指标市场机制管理模式探讨》，《资源与产业》2009 年第 2 期；马韬 《农转用年度计划管理制度尚需完善》，《中国土地》2012 年第 1 期。

④ “以租代征”在我国当下土地管理领域的频繁发生，一方面说明了这一违法用地现象的普遍性；另一方面亦暴露出我国现行土地用途管制制度的失灵。目前，学界围绕土地违法现象开展了诸多的研究，大多数的研究更多集中于如何治理这一违法现象，而较少从制度根源层面出发来寻求问题的根本解决，参见杨永磊、张光宏 《土地违法行为的法经济学根源及其有效治理》，《中国土地》2016 年第 2 期。

⑤ 参见周世荣 《土地隐形违法行为的表现形式和对策》，《中国土地》2017 年第 3 期；何跃军 《土地维权中的效用与制度创造——基于浙江省的实证分析》，《安徽师范大学学报》(人文社会科学版) 2015 年第 5 期。

⑥ 参见张先贵 《土地开发权与我国土地征收制度之改革》，《安徽师范大学学报》(社会科学版) 2016 年第 1 期；杨永磊、张光宏 《土地违法行为的法经济学根源及有效治理》，《中国土地》2016 年第 2 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和不二做法。[①] 然而，事与愿违的是，多次严格执法的结果，不仅不能从根本上有效解决问题，反而致使我国土地管理领域的违法现象有增无减。是故，为从根本上解决我国土地管理领域的诸多违法现象，急需我们转变处理问题的思路。

回到本文所探讨的农地开发许可权层面，在继续坚持传统农用地转用指标行政分配模式的基础上，立足于回应多元化的市场主体利益之诉求，借助市场化机制来解决各地农用地转用指标行政分配的弊端，亦即围绕农地开发许可权进行市场化改革，乃是转变我国传统土地管理模式，从制度层面解决问题的实质体现。这不仅有助于解决当下农用地违法转用这一现实难题，而且亦是我国土地管理制度面向市场化取向进行改革的理性选择。

其二，对我国农地开发许可权进行市场化改革，是充分发挥市场在土地资源配置中起基础性作用的体现。长期以来，由于深受计划经济体制的影响，我国的土地法律制度，尤其是土地管理法律制度的设计，无论是价值取向还是制度结构，更多的是借助于行政权力的单一方式来配置土地资源。[②] 反映在实证法层面，即单一的公法方式主导着我国土地资源配置的全过程。然而，伴随着我国市场经济的迅速发展，土地的财产属性得到极大的释放，土地市场上的多元利益主体诉求正日益凸显。传统以命令和服从为单一公法方式的土地资源配置模式，已逐渐呈现出系统性缺陷，致使其难以满足现实社会的发展需要。为此，引入市场机制，充分发挥市场在土地资源配置中的基础性作用，就成为引领当下我国土地法律制度改革，尤其是土地管理法律制度改革的基本指导思想。[③]

从实践来看，已为学界达成共识的是，无论是当下我国的土地财产权领域，还是土地征收权、土地用途管制权、土地规划权等土地管理权领域，其改革基本上都是以市场化取向为其理念选择，并在此基础上展开具体的制度重塑。[④] 譬如，在土地财产权领域，为了解决土地公有制背景下土地有偿利用难题，实现土地公有制与市场经济的顺利接轨，土地法权的制度设计亦经历了从土地所有权为中心到当下的以土地使用权为中心的转变。[⑤] 这一转变，不仅在较大程度上实现了土地产权清晰化的目标，而且亦推动了土地要素的市场化流转。[⑥] 此外，在我国的土地管理权领域，当下已在诸多地方开展的“集体经营性建设用地入市”、[⑦] “农村宅基地住房抵押”、[⑧] “三权分置”下的土地经营权流转等诸多政策试点方案，[⑨] 其本质上亦是对我国现行农村土地管理制度市场化改革的宣示。[⑩] 概言之，充分发挥市场在我国土地资源领域的基础性配置作用，已成为引领我国现行土地法律制度改革的基本路向，尤其在当下的土地管理法律制度领域表现得尤为明显。

实际上，在现阶段，土地供求关系处于不断的动态变化之中。土地供求方式已经从单一的行政划拨走向多元的市场化配置，土地供求的主体也更加多元化。因此，要真正实现对土地供求平衡的调节，土地利用总体规划和土地利用年度计划必须以市场化为导向，辅以合理的调控策略，从刚性调控向弹

① 这方面的政策性文件非常多，比如中共中央、国务院 1986 年 3 月下发的《关于加强土地管理、制止乱占耕地的通知》、1997 年 4 月下发的《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》、国务院 2001 年 5 月下发的《关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15 号)；国务院办公厅 2003 年 7 月先后发布《关于暂停审批各类开发区的紧急通知》、《关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》、国务院 2004 年 10 月下发的《关于深化改革严格土地管理的决定》、2006 年 9 月下发的《关于加强土地调控有关问题的通知》要求“必须采取更严格的管理措施，切实加强土地调控”等等。

② 张先贵 《〈土地管理法〉修改的理论争鸣与现实选择——兼论中国土地管理制度的走向》，《北方法学》2015 年第 5 期。

③ 阮兴文 《土地管理制度改革的正确方向是市场化——基于党的十七届三中全会精神的分析》，《社科纵横》2014 年第 3 期。

④ 白佳飞、杨继瑞 《中国土地制度改革市场化路径选择》，《西北农林科技大学学报》(社会科学版) 2016 年第 2 期。

⑤ 参见李凤章 《从公私合一到公私分离——论集体土地所有权的使用权化》，《环球法律评论》2015 年第 3 期。

⑥ 参见党国英、吴文媛 《土地规划管理改革：权利调整与法治建构》，《法学研究》2014 年第 5 期。

⑦ 参见张先贵 《土地开发权与集体经营性建设用地入市》，《北方法学》2017 年第 2 期。

⑧ 参见高圣平 《农民住房财产权抵押规则的重构》，《政治与法律》2016 年第 1 期。

⑨ 参见陈敦 《土地信托与农地“三权分置”改革》，《东方法学》2017 年第 1 期。

⑩ 参见高富平 《重启集体建设用地市场化改革的意义和制度需求》，《东方法学》2014 年第 6 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性调控的转变。[①] 基于这一背景，回到我国现行农地开发许可权层面，通过“自上而下、统一分配、层层分解、指令性配额”的农用地转用指标管理模式来解决农地非农化的资源配置问题，显然，乃是计划经济背景下通过单一的行政命令方式配置土地资源的实质体现。因此，引入市场机制，处理好政府与市场二者之间的关系，充分发挥市场在土地资源配置中的基础性作用，改变目前土地利用总体规划和土地利用年度计划下的用地指标行政配置的刚性模式，显然，这是当下改革我国现行农地开发许可权法律制度的理性选择。

当然，在此需要指出的是，在用地指标配置层面引入市场机制，并不是对传统用地指标单一行政配置模式的完全否认。正确的做法应是，承认用地指标行政配置为初次配置，市场化的用地指标配置乃是在克服用地指标初期行政配置之弊病的基础上而产生的二次配置。至于二次配置的规模和范围等重要问题，仍然需要国家本着公共利益的原则，着眼于国民经济健康、可持续的发展需要，进行合理的宏观调控。[②] 此外，在单一的计划配置模式被证明失灵的背景下，引入市场机制，通过二者的相互合作，而非做出非此即彼的选择，共同实现土地资源的优化配置目标，亦是顺应当下我国土地改革实践的现实需要。[③]

其三，对我国农地开发许可权进行市场化改革，是激励性土地管理理念和精神的实质体现和要求。从比较法层面来看，激励性土地管理理念乃是回应和平衡多元化市场主体利益诉求，调动被管理者积极配合管理的重要制度模式。[④] 伴随着改革我国现行土地管理呼声的日益高涨，学理上就当下我国土地管理制度的变革，如何引入激励性管理理念亦作了诸多的探讨。[⑤] 从现有的研究现状来看，虽然学界就这一理念如何嵌入到我国现行的地权结构规范体系中，存在诸多不同的判断和认知，[⑥] 但基本达成的共识是：以激励性管理理念和精神来重塑我国现行土地管理权，将传统的以“命令—服从”为单向度的管制模式转变为以双方协商为基本特征的柔性化管理模式，以此平衡多元利益之间的冲突，实现我国土地管理模式的弹性化目标。[⑦]

就当下我国农地开发许可权市场化改革实践而言，无论是早期的“两分两换”模式、建设用地“增减挂钩”模式，还是“地票”交易模式，其本质都在于，不断通过市场方式来获取新增农用地转用指标以解决指标行政配置单一模式之不足这一弊端。显然，相对于传统单一的刚性化指标管理模式，以市场的方式、通过交易来获取农用地转用指标，无疑为新增建设用地指标的获取开辟了疏的通道，而非一味地恪守单一的管制通道。实际上，有论证指出“土地指标的本质是中央政府对地方政府土地转用权数量控制的工具，指标交易则是下级地方政府对中央管制权的自主松动与调整”。[⑧] 显然，这种松动与调整的背后，本质上乃是对单一的公法管制模式所暴露出来的弊病进行内在调节的体现，并在承认地方政府具有自身独立利益诉求的基础上，[⑨] 按照市场化机制来回应这一独立的利益诉求。因而，就其实质而言，这一模式无疑是激励性管理理念和精神的鲜明表达。

---

① 龚华、李贵才：《快速城市化背景下土地利用总体规划转型研究》，《城市发展研究》2015 年第 12 期。

② 参见张齐武：《可交易许可模式在公共管理中的应用和移植——以公共住房政策为例》，《公共管理学报》2015 年第 2 期。

③ 参见高富平：《重启集体建设用地市场化改革的意义和制度需求》，《东方法学》2014 年第 6 期。

④ 徐建炜：《农地保护的国际经验及其对中国的启示》，《国际经济评论》2010 年第 2 期，第 124 页。

⑤ 参见郭洁：《土地用途管制模式的立法转变》，《法学研究》2013 年第 2 期；肖新喜：《我国农地管理制度的修改理念与规范配置》，《西北农林科技大学学报》(社会科学版) 2014 年第 2 期，第 8 页；赵宁：《土地利用规划激励性管制法律制度的实现》，《社会科学辑刊》2015 年第 1 期，第 67 页。

⑥ 参见杨惠、熊晖：《农地管制中的财产权保障——从外部效益分享看农地激励性管制》，《现代法学》2008 年第 3 期；黄金升、陈利根：《土地产权制度与管制制度的制度均衡分析》，《南京农业大学学报》(社会科学版) 2006 年第 1 期；张先贵：《容积率指标交易的法律性质及规制》，《法商研究》2016 年第 1 期。

⑦ 郭洁：《土地用途管制模式的立法转变》，《法学研究》2013 年第 2 期。

⑧ 刘羿、强甜甜：《比较法视野下土地指标交易改革研究》，《北方民族大学学报》(哲学社会科学版) 2016 年第 2 期。

⑨ 参见周飞舟、王绍琛：《农民上楼与资本下乡：城镇化的社会学研究》，《中国社会科学》2015 年第 1 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

另外，在土地财产权属性日益强化、土地利用主体和利用方式日益多元化的背景下，[①] 纠偏传统“命令—服从”之单一化的土地管理模式，实现向多主体间相互协作的治理模式之转变，是顺应国家从管理向治理的重大模式转变，满足国家治理现代化的现实需要。[②]

三、本质透视：农地开发许可权市场化改革的法理逻辑

在证成了我国现行农地开发许可权市场化改革具有法理上的正当性诉求后，接下来需要回答的问题是，实践中围绕我国农地开发许可权市场化改革而进行的诸多试点政策，能否获得法理层面的支撑，换言之，如何从本质层面来透视我国现行农地开发许可权市场化改革实践的法理逻辑？只有对这一问题给予有效的回答，方可为农地开发许可权法律制度的改革提供正确的理论指导。

毋庸置疑，实践是理论产生、发展和创新的动力。通过不断的总结实践规律，并将其提升到一般的法理层面，并进而在此基础上展开相关法律制度的建设，乃是立法所遵循的一般规律。这在我国当下的土地法领域，表现得尤为明显。对此，恰如有学者所言，“我国自 1978 年的农村土地制度改革，其形成的轨迹可归结为：实践先行、政策指导和法律兜底的‘三部曲’模式”。[③] 实践中，作为当下我国农村土地制度改革的三大法制课题 “三权分置”下的承包权与经营权分离改革、宅基地上的住房入市改革以及集体经营性建设用地入市改革，无不是先行试点，相关政策引导，法理论证，最后立法回应的鲜明体现。[④] 因此，立足于这一背景，遵循“先行试点——政策指引——法理论证——立法回应”的基本逻辑，对我国现行农地开发许可权市场化改革实践进行法理层面的求证，不仅对这一权力的市场化改革实践的顺利开展具有重大的指导意义，而且亦有助于打通政策与立法之间的通道，为政策要义向立法逻辑之转变提供前提性的话语支撑。[⑤]

在笔者看来，对我国现行农地开发许可权进行市场化改革，其法理逻辑是：在一定条件下，可借助私法的方式来完成我国的土地管理任务，实现我国的土地管理目标。当然，引入私法的方式来实现我国农地开发许可权的行使目标，并不是对传统单一公法方式的彻底否定。换言之，我国的农地开发许可权，在行使层面，应借助于公法与私法相互合作的方式，方可实现制度设计的目标。无论是单一的公法方式还是单一的私法方式，都非理性的选择。简言之，从法理上看，在一定的条件下，借助私法的方式来实现我国农地开发许可权行使目标，是我国农地开发许可权法律制度改革应坚持的理性路向。有鉴于此，下文拟对这一论题作深入探讨。当然，在此须指出的是，从我国目前农地开发许可权市场化改革的地方试点来看，从早期的“两分两换”、城乡建设用地“增减挂钩”发展而来的“地票”交易模式，代表了当下市场化交易水平最高、最为成熟的政策试点方案。[⑥] 为此，下文在展开这一主题时，着重以“地票”交易模式为参考样本和研判素材，并在此基础之上提升和穿透其试点方案背后的法理逻辑。

所谓“地票”交易，是指将农村闲置的宅基地、集体建设用地复垦成耕地后，在经相关土地管理部门验收合格后，由土地交易所购买，并折合成一定数量的建设用地指标，然后发给农户权利人用地指标的凭证即“地票”，相关单位或者个人可以到土地交易所购买该用地指标，以作为新增建设用地指标

① 蒋南平、徐慧 《地方政府对城市土地供给的影响研究：理论与实证》，《经济理论与经济管理》2015 年第 1 期。
② 张文显 《法治与国家治理现代化》，《中国法学》2014 年第 4 期。
③ 陈小君 《我国农村土地法律制度变革的思路与框架——十八届三中全会〈决定〉相关内容解读》，《法学研究》2014 年第 4 期。
④ 参见高圣平 《承包土地的经营权抵押规则之构建——兼评重庆城乡统筹综合配套改革试点模式》，《法商研究》2016 年第 1 期；房绍坤 《农民住房抵押之制度设计》，《法学家》2015 年第 6 期；朱广新 《土地承包权与经营权分离的政策意蕴与法制完善》，《法学》2015 年第 11 期；温世扬 《集体经营性建设用地“同等入市”的法制革新》，《中国法学》2015 年第 4 期。
⑤ 参见周仁标 《论社会稳定与地方治理》，《安徽师范大学学报》(人文社会科学版) 2017 年第 5 期。
⑥ 周立群、张红星 《农村土地制度变迁的经验研究：从“宅基地换房”到“地票”交易所》，《南京社会科学》2011 年第 8 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

凭证的来源。[①] 在相关单位或者个人从土地交易所通过招拍挂方式成功竞买该用地指标后，即为“地票”落地，此时竞买方持有该“地票”即可申请地方政府实施征地行为，而支付“地票”的价款则可以免交新增建设用地有偿使用费和耕地占补平衡补偿费。[②] 目前，虽然学界围绕“地票”交易这一新生事物展开了诸多的研究，但主要是集中在概念界定、功能和性质等层面，[③] 而鲜有从农地开发许可权市场化改革这一本质层面来展开深入、系统性研究，更遑论对这一权力市场化改革的法理逻辑予以揭示，进而为这一新生事物(试点政策)与现行法之有效接轨提供法理上的支撑。

实际上，就“地票”交易的本质而言，其实质乃用地指标的交易，借助于这种“指标”交易，能够在一定程度上解决城镇经济快速发展，而新增建设用地指标供给不足的弊端，对城市化的顺利进行起到重要的推动作用。上文已述，地方政府取得的新增建设用地指标乃是通过自上而下的行政分配方式取得的，由于各地指标分配不均的现实，经济发达地区获得的指标往往难以满足当地经济发展对土地的巨大需求，而不发达地区往往存在指标过剩的状态。虽然这种情形往往不利于土地资源在空间上的优化配置，但由于现行立法和政策对地方政府持有的新增建设用地指标进行交易持禁止的立场，[④] 因此，如何通过其他的手段在不影响 18 亿亩耕地红线保护的基础上，解决用地指标短缺就自然成为当下社会的一道难题。重庆的“地票”交易乃是破解这一难题的有效举措。其不仅解决了城镇建设用地指标供给短缺的现实难题，有力地支持了城市化、工业化的快速发展，而且亦有助于实现建设用地总量不增加，耕地总量不减少的弹性化土地管理目标。[⑤] 一系列理论和实证研究表明，要进一步释放中国经济增长的潜能，就必须进行建设用地指标的跨地区再配置，即“地票”交易。[⑥]

理论上，相对于传统的农用地转用指标行政分配模式而言，“地票”交易是借助市场交易这一私法方式，为新增建设用地指标的获取开辟了一条新的通道。可以说，“地票”交易这一私法方式的出现，是对传统指标计划配置所带来诸多负效应的有力弥补，是指标行政配置方式市场化取向改革的有益探索和实践。从某种意义上讲，我国现行的地票交易“类似于美国的土地发展权交易模式”。[⑦] 因而，在这一语境下，从法理逻辑层面而言，立足于当下的行政法学理论，不难看出，这种借助于私法的方式完成我国的土地管理任务，实现我国的土地管理目标的做法，从本质上讲，与通过私法的方式来完成行政管理任务的“行政私法原理”甚相契合，是“行政私法原理”在我国土地管理领域的深化发展、机制创新和实质体现。

从当下学界主流观点来看，在传统的行政法学原理谱系之下，基于秩序行政的原理，以公的主体和公法的方式来完成行政管理任务，实现行政管理目标，几乎成为理论研究、制度设计和规范配置所一致恪守的基本准则。[⑧] 然而，伴随着我国行政法治实践的迅速发展和学界对传统行政法学理论的深入反思，尤其是在给付行政理论迅速发展的当下，继续恪守传统行政法学下的通过单一的公的主体或者单一的公法方式，来完成行政任务，实现行政管理目标的做法，显然，难以顺应社会情势变迁之需要，难以适应行政任务多元化背景下的国家行政方式转型之需要。[⑨] 是故，在一定条件下，引入私的主体或

① 王绍洪 《重庆地票交易问题研究》，《西南民族大学学报》(人文社会科学版) 2013 年第 2 期。

② 参见杨继瑞、汪锐、马永坤 《统筹城乡实践的重庆“地票”交易创新探索》，《中国农村经济》2011 年第 11 期。

③ 参见程世勇 《“地票”交易：模式演进和体制内要素组合的优化》，《学术月刊》2010 年第 5 期；张先贵 《地票交易之地役权属性的理性检视》，《社会科学研究》2016 年第 1 期；谭峻 《重庆市地票交易制度评论》，《公共管理与政策评论》2013 年第 2 期。

④ 参见刘羿，强甜甜 《比较法视野下土地指标交易改革研究》，《北方民族大学学报》(哲学社会科学版) 2016 年第 2 期。

⑤ 参见范华 《新加坡白地规划土地管理的经验借鉴与启示》，《上海国土资源》2015 年第 3 期。

⑥ 参见程世勇 《“地票”交易：模式演进和体制内要素组合的优化》，《学术月刊》2010 年第 5 期。

⑦ 参见汪晖、陶然 《论土地发展权转移与交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式以及重要含义》，《管理世界》2009 年第 8 期。

⑧ 参见王锡锌 《行政正当性需求的回归——中国新行政法概念的提出、逻辑与制度框架》，《清华法学》2009 年第 2 期；朱新力、梁亮 《公共行政变迁与新行政法的兴起》，《国家检察官学院学报》2013 年第 1 期。

⑨ 参见徐健 《行政任务的多元化与行政法的结构性变革》，《现代法学》2009 年第 3 期；胡敏洁 《给付行政与行政组织法的变革——立足于行政任务多元化的观察》，《浙江学刊》2007 年第 2 期，第 22—28 页；郑春燕 《行政任务取向的行政法学变革》，《法学研究》2012 年第 4 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者私法方式，来完成行政任务，实现行政管理目标，改变传统行政主体或者行政方式单一化的理论局限，渐为行政法学理论内在结构更新升级的基本选择——学理上将这一变迁称为“新行政法现象”。① 这在当下我国的住房保障、养老保障等福利给付域已广泛存在，并被实践所运用。② 有鉴于此，为顺应这一发展趋势，在我国的土地管理改革实践中，在一定条件下，引入私法的方式来完成我国的土地管理任务，实现土地管理目标，不仅是“新行政法”原理在我国土地管理领域改革的深入发展、机制创新和实践体现，而且亦是转变我国传统土地管理践行单一的公法方式，适应当下市场在土地资源配置领域起基础性作用的内在需要。

实际上，在笔者看来，“地票”交易或者用地指标交易，其最大的优点是，能够立足中国当下城乡建设用地配置不均衡的现状，激励市场上私的主体来投入大量资金对农村闲置、低效的集体建设用地或者宅基地进行有效整治。这不仅是贯彻当下我国城乡建设用地“减量化”政策，③ 优化城乡建设用地空间布局的要求，而且亦能够实现政府在无须大量财政资金投入的背景下，满足公共物品或者公共服务的正常供给之需要。④ 是故，在公私法两种方式合作的理念指导下，借助于私法方式来完成行政任务，实现行政目标，不失为一条较为明智的选择，即能够较好地解决社会转型期利益主体需求的多元化与国家能力明显不足这一矛盾。⑤

此外，我国当下的土地开发整治⑥、城市“三旧改造”⑦、“城市更新”⑧等领域中所实施的 PPP 模式，即通过公私合作这种契约的方式来调动市场上私的主体的积极性，进而在此基础上实现政府的行政管理目标的做法，就其本质而言，亦充分体现了借助于私的主体或者私法的方式来完成土地管理任务，实现行政管理目标的“行政私法”原理。

综上述及，作为我国土地管理权重要组成部分的农地开发许可权，在践行传统单一的公法方式被实践证明已步入运行失灵困境的背景下，转变路向，化堵为疏，在一定条件下，引入私法方式，践行

---

① 参见江国华 《从行政行为到行政方式：中国行政法学立论中心的挪移》，《当代法学》2015 年第 4 期。

② 参见徐庭祥 《论以私法组织形式和行为方式履行行政任务的行政法规制——以分析住建部〈公共租赁住房管理办法〉为切入》，《甘肃行政学院学报》2013 年第 2 期；胡敏洁 《以私法形式完成行政任务——以福利民营化为考察对象》，《政法论坛》2005 年第 6 期。

③ 随着城镇化的快速发展，中国许多超大超市的建设用地规模接近极限，而建设用地布局分散、结构不合理、用地效率不高等问题较为普遍，以牺牲资源环境为代价换取经济增长的发展模式已广受诟病。2014 年，国土资源部出台《节约集约利用土地规定》和《关于推进土地节约集约利用的指导意见》，正式提出“减量用地”是实现节约集约利用土地的目标之一，“实施建设用地总量控制和减量化战略”。2015 年，中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》明确提出“完善资源总量管理和全面节约制度”，明确“实施建设用地总量控制和减量化管理”，建设用地减量化管理上升为国家战略举措。为适用经济发展新形势，上海市、江苏省等经济发达地区率先实行建设用地减量化，通过存量建设用地的高效利用减少对新增建设用地的需求，参见刘红梅、孟鹏、马克星、王克强、张冰松 《经济发达地区建设用地减量化研究——基于“经济新常态下土地利用方式转变与建设用地减量化研讨会”的思考》，《中国土地科学》2015 年第 12 期。

④ 参见喻文光 《PPP 规制中的立法问题研究——基于法政策学视角》，《当代法学》2016 年第 2 期；朱德新、朱峰 《土地非农化过程中的公私伙伴关系——以澳门新口岸为例(1962—1985)》，《西北农林科技大学学报》(社会科学版) 2015 年第 2 期。

⑤ 关于国家能力不足的详细论述，参见田孟 《耕地占补平衡的困境及其解释——基于国家能力的理论视角》，《南京农业大学学报》(社会科学版) 2015 年第 4 期；陈柏峰 《城镇规划区违建执法困境及其解释——国家能力的视角》，《法学研究》2015 年第 1 期。

⑥ 参见贾广葆 《土地一级开发整治引入 PPP 模式的若干思考》，《南都学坛》(人文社会科学版) 2015 年第 5 期；刘熙 《土地整治资金运行模式比较与改革探析——基于四川省实地调查经验》，《农村经济》2015 年第 8 期；顾守柏、刘伟、夏菁 《PPP 模式在上海土地整治中的运用》，《中国土地》2015 年第 9 期。

⑦ 参见吴次芳、王权典 《广东省“三旧”改造的原则及调控规制》，《城市问题》2013 年第 10 期；吴津 《关于旧城改造项目采取 PPP 模式风险分析与对策探讨》，《建筑设计管理》2015 年第 11 期；朱新现 《新型城镇化融资方式的转变——从土地财政到 PPP 模式》，《福建商业高等专科学校学报》2015 年第 3 期。

⑧ 参见王正安等 《PPP 模式在城市更新中的应用研究》，《建筑经济》2008 年第 9 期；朱海波 《当前我国城市更新立法问题研究》，《暨南学报》(哲学社会科学版) 2015 年第 10 期；严华鸣 《公私合作伙伴关系在我国城市更新领域的应用》，《城市发展研究》2012 年第 8 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

公私法相互合作的土地开发许可权运行模式，无论是理论还是实践，均具有显著的正当性诉求。因此，在笔者看来，面向市场化方向改革的我国农地开发许可权，在具体的路径层面，应该继续践行这一模式，并在此基础上寻求与现行法的有效接轨。当然，借助于指标交易这一私法方式来完成我国的土地管理任务，实现土地管理目标，并不是对指标行政配置这一公法模式的彻底否认。换言之，无论是践行单一的公法方式还是践行单一的私法方式，都是农地开发许可权在行使层面所无法承受之重的。故而，理性的选择应是，我国现行农地开发许可权在行使方式层面应践行公私法合作模式，即在不触动现行法的基础上，引入“地票”交易这一私法方式，并与传统指标行政分配这一公法方式相结合，乃是当下“最不坏”的选择。这一点，无论其改革成本，还是改革方案的妥当性，均值肯定。

四、结论与讨论：面向借助私法方式实现土地管理目标的未竟之课题

理论上讲，以命令和服从为单一公法方式的土地资源配置模式，实乃土地资源计划配置方式的鲜明体现，克服这一方式的弊端需要借用市场的手段。这一点无论是理论还是实践均无争议。① 尤其是在强调市场在土地资源配置中起基础性作用的当下，如何实现土地资源的市场化配置就显得尤为重要。在此须指出的是，计划与市场或者公法与私法两种土地资源配置方式，并非水火不容，非此即彼的关系，在某些情形下，将二者进行合作，协同运行，共同完成土地资源的配置往往是化解诸多难题的理性选择和有效出路。

实践证明，一国土地资源配置是否有效率，关键看两种方式合作程度的高低。进言之，无论是践行单一的公法方式，还是践行单一的私法方式，都是土地资源配置所不可承受之重的。唯有将这两种方式进行有效的配合或合作，方可实现土地资源的高效率配置。实际上，在土地资源管理公法领域，亦存在大量的借助于私法方式来完成土地管理任务、实现土地管理目标的现象。② 可以说，公私法之间并非非此即彼、势不两立的关系，二者之间的融合已弥漫到社会生活的各个角落，成为触手可及的客观存在。③ 尤其是在“公私法关系交错与互动”的当下，④ 只以私法或者只以公法来规制社会关系的做法已经越来越少，⑤ 越来越多的社会关系的规制形成了由公法与私法共同规制的局面。⑥ 在今日的市场经济体制下，市场需求无所不在，“公有私用”成为自然资源权利配置的实践逻辑。⑦

回到土地开发许可权层面，对现行的用地指标单一行政配置模式，按照市场化需要进行改革，乃是克服用地指标行政计划单一配置方式之弊端的理性选择。当然，这种市场化取向改革并不是对传统指标计划配置方式的全面否定，而是将二者有机地结合，即建设用地指标市场化交易是对建设用地指标行政配置的有益补充。用地指标的行政配置乃初次配置，而市场化交易乃二次配置。唯有如此，方能体现农地开发许可权行使的公私法合作模式，方能发挥二者共同实现土地资源的优化配置目标。

总体而言，本文围绕农地开发许可权市场化改革法理逻辑所做的研判，还只是一种粗线条的解释框架，尚有太多的问题仍需要作进一步深入的探讨。譬如，在何种条件下，可借助这种私法方式来实

---

① 参见秦鹏、孟甜 《土地资源市场配置机制的完善：以〈土地管理法〉修改的视角》，《重庆大学学报》(人文社会科学版) 2012 年第 1 期。

② 参见朱广新 《论违约行使土地使用权的法律后果——以私法规范在行政管理中的应用为视角》，《法律科学》2012 年第 2 期。

③ 税兵 《自然资源国家所有权双阶构造说》，《法学研究》2013 年第 4 期。

④ 苏永钦 《走入新世纪的私法自治》，北京：中国政法大学出版社 2002 年版，第 123 页。

⑤ [日] 吉村良一，张挺 《从民法角度看公法与私法的交错与互动》，《人大法律评论》2012 年第 2 期。

⑥ 实际上，当下我国自然资源配置领域，无论是从单一的公法方式还是从单一的私法方式去解读现行制度的内在机理，都无法获得准确的价值认知。是故，立足于公私法相互交融或合作的视角来审视制度的应然走向，已成学界之共识，参见马俊驹 《国家所有权的基本理论和立法结构探讨》，《法学研究》2011 年第 4 期。

⑦ 税兵 《自然资源国家所有权双阶构造说》，《法学研究》2013 年第 4 期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现农地开发许可权的行使目标？如何处理好农地开发许可权行使之公法与私法之间的衔接问题？在借助私法方式来实现农地开发许可权的行使目标时，如何对这一私法交易机制的风险进行法律规制？引入私法方式来实现我国的土地管理目标时，会给现有的法规范、法制度和法体系带来何种效应？围绕农地开发许可权制度重塑的法思想、法技术和法效果应作何种表达？等等，诸多问题，不一而足。由此我们可以说，就农地开发许可权的法律制度实践而言，中国法律人已经回答的问题远远少于有待进一步回答的问题，但这何尝不是拥有“后发优势”的研究者的幸运。

English Abstract

The Jurisprudence Logic of Market-oriented reform of Agricultural Land Development Permission: An Approach to Achieving the Goal of Land Management by Private Law

ZHANG Xiangui

Abstract: The right of farmland development permission is the expression of legal right of the examination and approval process of the conversion of agricultural land in China's "Land Administration Law". The core of the approval process of farmland conversion lies in whether it holds the index of conversion of agricultural land. On the theoretical level, the mode of agricultural land index management, which is "top-down, unified distribution, multi-level decomposition and mandatory distribution quota", is essentially a manifestation of the single-law method of "command-compliance" practiced by China's land administration. In practice, however, the violation of the conversion of agricultural land is more frequent, which reflects the plight of the operation of agricultural land development permission. The land policy has shifted from the two for two policy, link the increase and decrease of the land for construction use in both urban and rural areas, to the policy context of the "ticket" transaction. Although it breaks the predicament that has been obtained from the target plan with the system function and value of diversion rather than blocking, but the logic behind it is the essential declaration of market-oriented reform on the development permission of agricultural land. At the level of jurisprudential logic, the market-oriented reform of agricultural land development permission reflects the principle of administrative private law, which is, of course, the deepening development, mechanism innovation and practice of the principle of "administrative private law" in our country's land administration. The legal system of land administration should also take this as an opportunity and entry point to start substantive reforms.

Key Words: approval of agricultural land conversion; farmland development permission; public law; private law

责任编辑 李晶晶
责任校对 王治国

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net